

1501904-87.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... sabido que dependentes químicos utilizam o tráfico de entorpecentes como meio de perpetuar o vício, de modo que as condutas coexistem, não se excluem, donde afastado o pedido de desclassificação.

Neste sentido: A condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501904-87.2021.8.26.0537 - Controle nº 2021/001416

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2266200/2021 - 04º D.P. DIADEMA, 2266200 - 04º D.P. DIADEMA, 2023/21/129 - 04º D.P.

DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Eudes Pereira do Nascimento

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

EUDES PEREIRA DO NASCIMENTO, qualificado às fls. 09/10 e 15, está sendo processado pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 29 de setembro de 2021, por volta das 09h45, na Rua Imbauva, altura do n.º. 243, bairro do Inamar, nesta cidade e comarca de Diadema trazia com ele e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 12 porções contendo 9,1g da droga cocaína, 27 porções contendo 10,1g da mesma droga, na forma de crack, e 39 embalagens plásticas contendo 71g da droga maconha, conforme auto de apreensão e exibição de fls. 06/07 e laudo de constatação provisória de fls. 19/21, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls.38/41), o réu foi notificado e citado (fls. 69/70 e 110), e apresentou defesa preliminar através do Defensor

Público que lhe foi nomeado. Não sendo hipótese de arquivamento, a denúncia foi recebida em 14/02/2022 (fl.85).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas comuns arroladas tempestivamente e interrogado o acusado ao final, encerrando-se a instrução processual sem requerimento de diligências, seguindo-se com os debates orais (tudo em mídia digital).

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Pleiteou a fixação das penas base acima do mínimo diante da grande quantidade e nocividade da droga cocaína, em que pese a confissão do réu, que entende não ter havido em juízo, mas excepcionalmente que deve ser compensado com uma de suas reincidências, discordando da redução da pena e de sua substituição por reprimenda restritiva de direitos, fixando-se regime prisional fechado, sem possibilidade de apelo em liberdade, e sim a perda do numerário apreendido.

Já o d. Defensor Público reiterou seu pedido de absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu que a pena-base seja fixada no mínimo legal, compensando-se a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena ainda que em patamar menor, com sua substituição com fulcro no art. 44 do CP, fixando-se regime mais brando, e possibilidade do acusado recorrer em liberdade, até pela detração penal.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fl. 07/08, nos laudos de constatação e no definitivo (fls.19/21 e 111/113), ambos positivos para as drogas cocaína e maconha.

A autoria é inconteste não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos policiais militares (fls.13/14), realizavam patrulhamento pela Rua Imbauva, onde sabiam de ante mão acontecia tráfico de entorpecentes, quando avistaram o indiciado aqui presente, o qual, ao ver a aproximação da viatura Policial, empreendeu fuga em desabalada carreira. Desembarcaram da viatura e foram ao encalço do indiciado, logrando detê-lo alguns metros à frente, sem que tivessem perdido ele de vista. Ao procederem busca pessoal no indiciado, encontraram na sua cintura, por debaixo da camisa que trajava, uma sacola plástica a qual acondicionava, aparentemente, substâncias entorpecentes. Indagado sobre os fatos, ele confessou que estava traficando drogas naquele local.

Sob o crivo do contraditório o policial Amaro Serafim confirma os fatos e reconhece o réu. A sacola estava no corpo dele, com as drogas e dinheiro. O local é um ponto de venda de drogas conhecido, e assim que o réu os viu, empreendeu fuga a pé. Desembarcou e conseguiu aborda-lo. Em busca pessoal, a sacola foi localizada na cintura do réu. Não perdeu o réu de vista, e ele confessou estar na venda de entorpecentes e que seria usuário também. O réu não estava maltrapilho nem sujo.

Igualmente o policial Gustavo Ortiz alegou que estavam em patrulhamento, em local conhecido por venda de entorpecente. Seu parceiro desembarcou e seguiu o acusado, conseguindo detê-lo em polder das drogas e dinheiro. Ele confessou a traficância e ele era procurado. Drogas e dinheiro proveniente da venda de drogas estavam na sacola na cintura quando da fuga.

O réu, em solo policial (fl.15) respondeu que na manhã de hoje, estava vendendo drogas na esquina da Rua Imbauva, quando viu a chegada de policiais militares, e

tentou fugir do local, mas não conseguiu. Foi abordado e encontrado em seu poder as substâncias entorpecentes que traficava. Tinha chegado no local havia poucos minutos e tinha vendido dois invólucros com maconha. Recebe pelo dia de trabalho a quantia de R\$ 150,00. Não sabe dizer para quem trabalha, sendo que recebeu a droga de um desconhecido que ali chegou de moto, não tendo visto o rosto dele. Está desempregado e é usuário de drogas. Quanto ao fato de ser procurado pela Justiça, alega que deixou de assinar a carteira do benefício que teve da Justiça, junto ao Fórum, em virtude da pandemia.

Em juízo o acusado disse que estava passando fase difícil no casamento e acabou se afundando nas drogas. Trabalhava como eletricista e pelo seu estado emocional, passando com psicólogo, acabou seu dinheiro, pegou fiado para usar a droga e os traficantes disseram que se não pagasse naquele dia, tinha que segurar as drogas até o meio dia ou algo pior ia acontecer pra ele, assim, teve que traficar para eles, mas foi preso antes.

Logo, a confissão extrajudicial e a informal, que não é prova única, até porque veio corroborada pelos relatos dos testemunhos dos policiais - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, sem prova contrária.

E nem se alegue haver apenas o relato dos policiais a embasar a condenação, pois o Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do e. STJ é no sentido de que: É cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais. A defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos policiais militares, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento.

E como já visto, o réu confessou informal e extrajudicialmente estar traficando no dia e hora dos fatos, o que foi reiterado pelos depoimentos dos policiais, que sempre afirmaram que o réu, por eles reconhecido, foi o indivíduo que correu assim que percebeu suas presenças, e que era ele quem portava a sacola com as drogas, e quem lhes confirmou informalmente estar traficando, ainda que não presenciado qualquer ato de comércio, mas as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares de guardar e trazer consigo, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

No mais, a condição de usuário de drogas que o réu alega, e não faz prova - não trouxe testemunhas, nem mesmo seus pais que teriam o inscrito num curso/internação, nem documento nesse sentido, tão pouco afasta a traficância, uma vez que é comumente sabido que dependentes químicos utilizam o tráfico de entorpecentes como meio de perpetuar o vício, de modo que as condutas coexistem, não se excluem, donde afastado o pedido de desclassificação.

Neste sentido: A condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira).

Afasto, ainda, tese de estado de necessidade, ou coação moral irresistível, ou desemprego, pois os bens jurídicos são desproporcionais, por se colocar em risco a saúde pública, de interesse da sociedade, em detrimento do interesse individual, além de se tratar de crime de perigo abstrato. Ademais, não há prova nos autos de que o réu passava por miserabilidade extrema a ponto de ter que violar a lei para

sobreviver. Ou que tenha sido coagido por traficantes à comercializar drogas para pagar dívida, até porque essa versão não foi a apresentada desde o início, como seria o normal e correto caso ela fosse verídica. Mas como já visto, o acusado não trouxe nenhuma prova a indicar ser usuário e dependente químico. Por fim, admitir a falta de emprego como causa excludente de ilicitude seria legalizar a prática de crimes por todo e qualquer indivíduo que esteja desempregado e em precárias condições econômicas - o que não é aceitável.

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza das drogas (cocaína e maconha e crack), a quantidade de narcóticos (78 no total), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), apreensão de numerário (fl.6/7) são fatores que reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável. Ainda que se trate de agente que se diz usuário, situações que não se opõe, e sim coexistem.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências dos delitos, a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas que não reputo excessiva (78 no total), fixo em primeira fase, a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, cada um desses fixados em um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do condenado.

Em segunda fase, presente circunstância agravante da multirreincidência, e também a atenuante da confissão informal e a extrajudicial espontânea, que por envolver a personalidade do agente, são igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67 do Código Penal" (STJ, REsp n. 1.154.752/RS, 3ª Seção, DJE 4.9.2012). Assim, compenso a reincidência comprovada a fl. 22 (por crime de tráfico condenado pela 1ª Vara Criminal de Diadema) com a atenuante da confissão, porque também me vali dessa prova a embasar a condenação, e por questão de justiça, ora deve ser acolhida. Mas considerando a condenação definitiva comprovada a fl. 23, por furto, junto a esta 2ª Vara Criminal de Diadema, agravo a pena em 1/6, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão mais 583 dias-multa. Considerarei as duas condenações como duas reincidências/agravantes, face ao princípio da proporcionalidade.

Em terceira fase, não concorrem causas de aumento de pena. Nem o privilégio previsto do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, por se tratar de réu reincidente específico (fl. 22), a indicar que faz do crime seu meio de vida, inaplicável a ele a benesse, por expressa vedação legal.

Cito jurisprudência neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO ANTERIOR POR USO DE DROGAS. ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 - REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. [...] Correto o acórdão estadual ao deixar de aplicar o redutor do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, porquanto a reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/02/2018) grifo nosso.

Incabível a aplicação da benesse do art. 44 do CP, por ausentes os requisitos: objetivo (pena maior aos 4 anos máximos permitido) e subjetivo (agente é reincidente específico). Ademais: Entorpecente - Tráfico - Substituição de reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Incompatibilidade da Lei 9.714/98 com a Lei 8.072/90, que equiparou essa espécie de crime aos hediondos, punindo o traficante com maior severidade, inviabilizando, inclusive, a concessão de benefícios, como a liberdade provisória e a progressão de regime. (TJAP) RT 772/617. Em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, e

em que pese a

Atenta às diretrizes do art. 33 do Código Penal, considerada a plurirreincidência do réu e quantidade da reprimenda, fixo como adequado o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o fechado, por entender ser o necessário e o suficiente para a reprovação da conduta e para a prevenção do crime praticado, até pela preponderância da natureza (cocaína e crack) e da quantidade da droga (que embora não seja excessiva, é considerável), não ficando o juiz obrigado a fixar regime inicial relacionado unicamente com o quantum da pena, podendo optar por um mais gravoso ao observar a regra do artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei 11.343/2006, por conta da quantidade considerável de droga apreendida e sua natureza altamente lesiva e viciante para estabelecer o regime prisional mais gravoso (Vide: AgInt no REsp 1.539.980/PR, j. 11/04/2019).

Deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Inclusive, o réu está preso há menos de quatro meses, e sem direito sequer à progressão de regime.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais.

Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, verificada a possibilidade concreta da continuidade de práticas delitivas por multirreincidente, bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, estando desempregado. (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC n.º 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC n.º 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC n.º 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC n.º 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra EUDES PEREIRA DO NASCIMENTO, qualificado às fls. 09/10 e 15, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º

11.343/06 e o faço para condená-lo à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 583 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos, corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

O condenado não poderá apelar em liberdade. Recomendo-o no cárcere em que está.

Sendo ele assistido pela DPE, reconheço suspensão a exigibilidade de pagamento das custas e despesas processuais, por ora.

Decreto a perda de numerário apreendido (fl.06/07), por ser proveniente da venda de drogas, com fulcro no art. 63 da Lei 11.343/06. E determino a destruição de todas as drogas.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa, intime-se o réu a paga-la em 10 dias sob pena de extração de certidões da Sentença para a Procuradoria Geral do Estado (dívida ativa).

Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA